

1502908-94.2019.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... travessa da rua Santo Ivo. Estava preso por tráfico. Fazia bicos com seu tio. Tinha sido demitido do McDonalds na véspera, e ia levar seus documentos para dar baixa na carteira, pois estava de experiência. Não sabe explicar como foi reconhecido. Às reperguntas da Defesa, disse que estava em casa e os policiais vieram lhe buscar em sua casa com um mandado de prisão. E no outro dia foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502908-94.2019.8.26.0161 - Controle nº 2019/002310

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2335407/2019 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caio Henrique Batista da Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

CAIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA, qualificado indiretamente às fls. 108, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma dos artigos 29, caput, e 70, caput, todos do Código Penal, porque no dia 29 de outubro de 2019, por volta das 19h30, na Rua Santo Ivo, altura do nº 267, bairro Casa Grande, nesta cidade de Diadema, atuando previamente ajustado com outros dois indivíduos não identificados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Josinaldo Jose de Aquino e Edilan, subtraiu, para eles, uma carteira contendo documentos pessoais e a quantia aproximada de R\$6.000,00.

Decretada prisão temporária (fl. 184) a qual foi convertida em prisão preventiva quando do recebimento da denúncia em 20 de maio de 2021 (fl.189). Citado (fl.258), o réu apresentou defesa inicial feita por Advogado constituído (fls.269/275).

Em audiência una foram ouvidas vítimas, testemunhas arroladas pelas Partes e interrogado o réu ao final.

Em debates orais, o d. Representante do Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, fixando-se a pena-base acima do mínimo legal, com a agravante da emboscada, e os aumentos pelas majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, fixando-se regime fechado, sem possibilidade de substituição da reprimenda nos moldes do art. 44 do CP, nem de apelo em liberdade.

Já o d. Advogado requereu prazo para juntada de memoriais, mas por seu pedido ser tardio e sem possibilidade do MP ter tido a mesma oportunidade, valendo-me do disposto na lei acerca da audiência una de instrução, debates e julgamento, foi indeferido e o mesmo passou a se manifestar em debates orais, quando pretendeu a absolvição sumária do réu ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, afastando-se as duas majorantes, fixando-se regime menos gravoso, até pela detração penal a permitir, ainda, a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos e o apelo em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva assim como a autoria veem demonstradas pelas provas que sigo analisando.

A vítima Josinaldo narrou ter sido contratado por Edilan para fazer um carreto. Rumaram ao local combinado para a retirada da moto e entrega do pagamento. Assim que chegaram ao ponto indicado, o denunciado e seus comparsas lhes abordaram e anunciaram o roubo, ameaçando-lhes com uma arma de fogo, e lhes agredindo com socos, subtraindo sua carteira e o dinheiro levado por Edilan para pagar a moto.

Sob o crivo do contraditório essa vítima reiterou que fazia carreto e o Edilan lhe chamou. Quando chegaram no local dos fatos, do lado de uma viela, numa rua estreita, viu dois rapazes descendo de casaco e touca, e estranhou, e falou para Edilan para irem embora. Eram três rapazes, dois morenos e um menor, e um deles estava armado, um dos morenos que passou para o menor e ficavam falando para atirarem neles porque Edilan não dava o dinheiro que estava na cueca, e seu dinheiro do carreto ficou na pochete na porta do carro. Eles lhe chutaram e caíram no chão, e também recebeu três socos, um na costela e dois na barriga, e disseram que iam lhe matar, quando grudou num pelo pescoço, o outro apontou a arma e ia atirar, então entrou para baixo do carro. Eles também deram socos e chutes no Edilan que não entregava o dinheiro, até que puseram a mão dentro da cueca dele, pegaram, e foram embora com os quatro mil reais aproximadamente, o boné, o tênis e o celular do Edilan. Eles pegaram sua carteira com documentos e pediu para devolverem porque não tinha dinheiro, e eles jogaram. Várias pessoas viram, mas não puderam ajudar. Pegou o carro e voltou para pegar um documento dele que caiu, e eles vieram de novo e se abrigaram no sacolão. Reconheceu o réu meses depois no DP, e hoje também, como sendo um dos morenos, o magro, mais alto que si, e que foi quem lhe agrediu muito, e como estava com o rosto descoberto, recorda-se bem dele. Às reperguntas do MP, disse que os meliantes chegaram anunciando o roubo e mandando entregarem o dinheiro. E às reperguntas da Defesa disse que foram mostradas duas fotos de dois rapazes, e reconheceu só um deles. A arma estava com o réu, que entregou para o do meio, que acha que era o menor de idade, branquinho, quem agrediu muito tanto a si quanto ao Edilan, na cabeça, dando chutes, e depois foi para a mão do terceiro meliante, que também pegou na arma. Achou que ia morrer e ficava de olho na arma porque eles iam atirar a qualquer momento.

Neste sentido foi o relato do policial Cleber Matias de que estavam investigando o réu e outros indivíduos que moravam na rua Santo Ivo. Eles anunciavam um bem pela internet com valor abaixo do de mercado, e marcavam o encontro na citada rua para que pudesse fugir para sua casa numa rua próxima. Segundo as vítimas, chegaram com o dinheiro para comprar a moto e o guincho, e foram enquadradas pelo réu e outros dois meliantes, que levaram os três mil reais do Caio e do Josinaldo a carteira com dinheiro, celular, e ele também sofreu agressões físicas, coronhadas, socos. Essa vítima reconheceu o réu com certeza e também reconheceu um dos rapazes por foto das redes sociais do Caio, de nome Renato. Nada foi recuperado. Segundo Josinaldo, eram três os roubadores, e deixou bem claro que Caio foi quem reconheceu sua carteira. Quem portava arma de fogo seria o Renato, o branquinho. Ele também foi agredido fisicamente na cabeça e barriga pelos roubadores. Após a prisão do acusado e do irmão dele, acabaram os roubos na citada rua, e diversas pessoas de uma Igreja Evangélica também denunciavam roubos no local, mas não faziam BO contra os irmãos de alta periculosidade, por temerem represálias, e desde a prisão dos réus, não há mais roubos contra os evangélicos. Reconhece o réu.

O réu não foi ouvido extrajudicialmente. E sob o manto do contraditório, o acusado disse não conhecer o Josinaldo e quando ocorreu esse fato estava na casa de sua mãe, e moram ali perto, numa travessa da rua Santo Ivo. Estava preso por tráfico. Fazia bicos com seu tio. Tinha sido demitido do McDonalds na véspera, e ia levar seus documentos para dar baixa na carteira, pois estava de experiência. Não sabe explicar como foi reconhecido. Às reperguntas da Defesa, disse que estava em casa e os policiais vieram lhe buscar em sua casa com um mandado de prisão. E no outro dia foi lá porque o Advogado falou para ele ir, e ficou preso. Não conhece a vítima e não tem arma e não usou de violência.

Contudo, nem o réu nem a Defesa fizeram prova de onde o réu estava ou o que fazia no dia e hora do crime, tendo alegado que havia sido dispensado de seu trabalho e ia levar os documentos para dar baixa na carteira, mas não demonstrou nada do alegado, até porque, pelo horários dos fatos, à noite, não faria nada disso.

Resumindo, tem-se a negativa de autoria não esclarecida nem comprovada pelo acusado, e por outro lado as declarações uníssonas e coesas da vítima, juntamente com o reconhecimento pessoal positivo feito em audiência, que corrobora o reconhecimento fotográfico de fl. 11/13, feito extrajudicialmente, tudo somando ao depoimento do policial, sem prova contrária.

Nesse ponto, vale ressaltar que os depoimentos e testemunhos colhidos são harmônicos e idôneos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova concreto tendente a torna-los suspeitos, razão pela qual são acolhidos sem reservas por este Juízo. E mais: (...) as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconhecidas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos RJTACrim 43/233). Ora: No roubo, por suas peculiaridades, dentre as quais a clandestinidade, é o relato da vítima que possibilita a reconstituição dos fatos e a identificação do agente. (TACrim, Processo: Apelação n.º 1472149/1, Relator: Ubiratan de Arruda, 9.ª Câmara, Julgamento: 16.03.2005, votação unânime). E o que dirá no caso em tela em que houve duas vítimas, tendo Josivaldo reconhecido o réu com segurança e certeza, não havendo que se falar em fragilidade do reconhecimento ou este não ter sido feito com outras pessoas, dado que a lei assim não o exige, e a vítima afirmou ter tido contato visual com o réu, quem estava sem máscara nem capuz, e ficou consigo por tempo suficiente, não havendo dúvida acerca do seu reconhecimento. E mesmo que o ofendido Edilan não tenha prestado declarações, tal fato não exclui o roubo contra si porque presenciado pela vítima Josinaldo, o que basta à comprovação da autoria e materialidade, até por não haver prova contrária.

A majorante do emprego de arma de fogo também se faz presente, pois sempre afirmada pelo ofendido, ainda que não tenha havido sua apreensão e realização de perícia. Observe-se como esse entendimento está há muito pacificado na jurisprudência: STF, HC 107.234-MG, 1ª Turma, Rel. Ricardo Lewandowski, 25/05/2011, v.u.; STJ, HC 111.839-MT, 1ª Turma, Rel. Luiz Fux, 22/05/2012, v.u.; TJSP, Ap. 906.377.3/6, 7ª Câmara Criminal, Rel. Ivan Marques, 25/05/2006, v.u.. Por todos: "Apelação Criminal - Roubo qualificado pelo de arma e concurso de agentes - Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, seus reconhecimentos e pelos depoimentos dos policiais ouvidos - Absolvição - Impossibilidade - Qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes comprovadas pela prova oral, sedo desnecessária a apreensão da arma e sua submissão à perícia - Pena e regime prisional corretamente fixados - Sentença mantida - Apelo improvido. (grifei)

O concurso de agentes também é incontestado nos moldes da mesma fundamentação supra, ou seja, dado que as vítimas sempre afirmaram que o réu não agiu sozinho, mas previamente ajustado e com divisão de tarefas com outros meliantes, anuídos do mesmo propósito, com divisão de tarefas, causando mais danos, eliminando chance de reação/defesa.

E o concurso formal de crimes, patente na conduta do réu, que mediante uma só ação, roubou duas vítimas distintas, ciente disso, dado que subtraiu a carteira de Josinaldo, ainda que a tenha dispensado posteriormente, e o dinheiro, boné, tenis de Edilan, que não foram recuperados.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, tem-se anormal reprovabilidade da conduta do agente ante a intensidade das agressões físicas contra as vítimas, mediante socos na costela e abdômen, chutes enquanto estavam já caídas, coronhadas nas cabeças perpetradas não apenas pelo réu como pelos comparsas, o que somado às circunstâncias do crime, que se deu após atrair a vítima ao local de sua conveniência para abordá-la e conseguiu fugir para sua casa onde se homiziaria, além do valor elevado de objeto material (valor uma motocicleta) que demandou maior determinação criminosa para sua subtração, tendo em vista as dificuldades inerentes ao roubo do bem e dos consideráveis prejuízos causados às vítimas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, por esses motivos, fixo em primeira fase, tem-se 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas (fls. 197/200), restando a pena inalterada nesta etapa, pois considerado como circunstâncias do crime o modo como a vítima foi atraída ao local da emboscada.

Por fim, em terceira fase, sem causa de diminuição da pena. E a aumento em 1/3 pela majorante do concurso de três agentes, completamente desnecessário e a causar mais temor e facilitar a consumação do crime ante a eliminação de possibilidade de defesa pelas vítimas, perfazendo 08 anos de reclusão e 20 dias-multa. A qual elevo em 2/3 pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, desnecessária dado o emprego de violência física também empregada através de socos contra os ofendidos, totalizando 13 anos e 04 meses de reclusão mais 33 dias-multa. Explico esses percentuais.

Considerarei estes dois aumentos porque: ... com a nova redação do art. 157, do Código Penal, trazida pela Lei nº 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração

na terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2.º do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3 até a metade e, no § 2.º-A, I, majoração fixa em 2/3 para a hipótese de emprego de arma de fogo (...)" (TJSP. 4.ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0062757-50.2018.8.26.0050, rel. CAMILO LÉLLIS, j. 30/04/2019, v.u.)- grifei.

Acolher apenas o percentual maior (de 2/3) para roubo praticado com emprego de arma de fogo e outra causa de aumento de pena seria apenas igualmente crimes mais graves e menos graves, e portanto, fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não se fazendo justiça.

Inclusive o e. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes autorizando a aplicação de fração de aumento acima do mínimo legal quando evidenciadas tais circunstâncias concretas. Neste sentido: "(...) Cite-se como argumento subsidiário que o art. 157, § 2.º, II, do CP prevê como causa de aumento a utilização de arma, que pode ser branca ou de fogo. Quando o agente se utiliza de arma de fogo, a reprovabilidade da conduta é inequivocamente maior. Transborda-se, em muito, o elemento abstrato que compõe o delito de roubo majorado. Trata-se de roubo que muito se aproxima da tentativa de homicídio ou do latrocínio. A conduta é severamente reprovável sob a ótica do Direito Penal. (...) Ademais, entre as várias causas de aumento previstas no dispositivo, é evidente que um critério qualitativo, não meramente quantitativo, conduz a que se imponha maior reprovação à utilização da arma de fogo. (...) Tanto há maior reprovação da conduta que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o uso de arma de fogo justifica o agravamento do regime prisional (STJ, REsp 1582665, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado 16/06/2016, grifei).

Por fim, aumento essa pena em 1/6 diante do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), pois feitas duas vítimas mediante uma só ação delitiva, totalizando assim: 15 anos e 06 meses de reclusão mais 38 dias-multa.

Incabível a substituição do art. 44 do CP, pois ausentes os requisitos legais, o objetivo (pena superior a 4 anos), e por entender não ser suficiente para a reprovação da conduta nem para a prevenção do crime praticado, menos ainda socialmente recomendável, até pelo emprego de grave ameaça e também de violência física excessiva contra às pessoas.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, a quantidade da reprimenda, a audácia e periculosidade do agente que efetivamente se armou e empreendeu a grave ameaça contra a vítima, e ainda a agrediu fisicamente, além da gravidade do crime praticado com a presença de comparsa a indicar covardia e gerar maior intimidação aniquilando chance de defesa, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado. Ademais: "O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado ao agente que comete delito de roubo qualificado é o fechado, diante de sua periculosidade, circunstância esta que justifica o estabelecimento do regime mais rigoroso. Esse E. Tribunal decidiu que ainda que menor e primário o agente que participa de assalto qualificado não disfarça evidente periculosidade, irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada" (JUTACRIMSP 91/117) – grifo nosso.

E nem se alegue que o tempo de prisão por este feito, menos de seis meses nos quais há de ser considerado ainda, o recesso de fim de ano, tenha o condão de abrandar o regime, ou justificar uma progressão. Por isso, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso,

progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado, sem comprovada residência, estando em situação de rua, tratando-se de criminoso habitual segundo sua extensa folha de antecedentes, sendo incongruente soltá-los, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Recomende-se-o no cárcere em que está. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC n.º 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC n.º 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC n.º 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC n.º 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

O fato do réu ter dois filhos pequenos que dependem de si não autoriza o recurso em liberdade, até porque as vítimas e os moradores da comunidade também são pais de família, seus filhos também dependem deles, não podendo o direito do réu se sobrepor ao da comunidade, que almeja paz e segurança, de modo que para a garantia da ordem pública, dado que o réu já foi processado por crime de tráfico e, segundo o policial Cleber Matias ele era apontado por outras vítimas como sendo o roubador nos mesmos moldes que o crime em tela, sua prisão é de rigor, não apenas para recorrer, mas para cumprir a pena em regime mais gravoso, o único suficiente e eficaz à reprovação da conduta perigosa e agressiva do réu, e sua ressocialização.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano por não haver prejuízo patrimonial.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra CAIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA, qualificado indiretamente às fls. 108, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma dos artigos 29, caput, e 70, caput, todos do Código Penal, e o faço para condená-lo à pena de 15 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento total de 38 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos.

Sem condenação nas custas e despesas processuais ante a justiça gratuita concedida a fl. 283.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal e:

- 1) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;
- 2) certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu para pagamento no prazo de 10 dias, em favor do FUNPESP;
- 3) oficie-se ao IIRGD e ao e. T.R.E. ;
- 4) comuniquem-se as vítimas nos termos do art. 201, §2º, CPP.

Diadema, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA